

1513849-28.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Os três admitiram a prática do tráfico. Não havia pessoas próximas. Os réus foram detidos na via pública. Não se lembra se havia anotações de tráfico. Não conseguiu visualizar se a bolsa foi arremessada para fora por algum morador, não soube esclarecer a pergunta do promotor sobre essa questão. Não é verdade que o réu Matheus tenha sido detido dentro da casa. Não viu os réus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513849-28.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513849-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152056/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 18324544 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2374/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2152056 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE RAUL PEREIRA DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

HENRIQUE RAUL PEREIRA DE OLIVEIRA e MATHEUS SILVA DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 05 de junho de 2021, por volta das 9h00min, na Rua Euricles Formiga, altura do nº 100, bairro Cidade Líder, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso previamente ajustado e unidade de desígnios com o adolescente João Gabriel Freitas, traziam consigo, para fins de comércio, 50g de "cocaína", divididos em 35 porções; 4,3g de "cocaína", divididos em 7 porções; 48,5g de Tetrahydrocannabinol, conhecido popularmente como "maconha", divididos em 17 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito, sendo convertida a prisão em preventiva após decisão de fls.91/95.

Os acusados foram notificados (fls. 145 e 147) e apresentaram defesa preliminar (fls. 154).

A denúncia foi recebida em fls. 155.

Acostado aos autos o laudo de exame toxicológico (fls. 188/190).

Os acusados foram devidamente citados em fls. 199/200.

Iniciada a instrução, não foi possível a realização da audiência de instrução, em razão da não apresentação dos acusados em Juízo (fls.207/208). Em novo ato, foram ouvidas três testemunhas comuns, sendo requerido pela defesa a oitiva de duas testemunhas do Juízo (fls.236/237). Designada nova data, uma testemunha do Juízo foi ouvida e os réus foram interrogados (fls.254/265).

Declarada encerrada a instrução do feito, o Ministério Público, em memoriais, pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito, bem como requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante de sua reincidência, e a fixação do regime fechado para cumprimento da pena aplicada (fls.269/280).

A d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probante, considerando que a prova amealhada aos autos resume-se ao depoimento dos policiais, revestidos de contradições. Alegou que a negativa do acusados veio corroborada pelo testemunha do adolescente João Gabriel, que admitiu o delito, bem como pelo depoimento da testemunha Eduardo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação, com relação ao réu Matheus, para o delito previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/06, especialmente diante do depoimento dos próprios policiais que alegaram que quem portava a sacola com as drogas era o acusado Henrique, sendo Matheus e o adolescente seriam os olheiros. Requereu, ainda, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, a aplicação da pena mínima, a fixação e regime menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade (fls.287/301).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade delitativa encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/15), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação de fls. 58/61 e laudo químico toxicológico (fls. 188/190), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha João Gabriel Brito Freitas, adolescente disse que conhece os réus de vista, da comunidade onde moram. Estava parado na viela, sozinho, traficando. Ao avistar a polícia, correu na direção de uma casa próxima, onde estava Matheus, dormindo. Henrique estava parado perto dessa casa. Os policiais entraram na casa. Disseram que Henrique era o olheiro, o que não era verdade. Os fatos ocorreram no período de manhã, por volta de 8h ou 9h, não havia mais gente na rua, mas apenas um usuário, que já era conhecido dele. Não viu se havia outras pessoas dentro da casa. Todos os entorpecentes estava com ele.

A testemunha Braitiny Cecilio de Aguiar disse recebeu denúncia de transeunte informado o nome da rua na qual havia três indivíduos parados, próximos de um poste. Eles correram ao avistar a viatura, o que ensejou a abordagem. Os três conseguiram correr, tentaram empurrar a porta de uma casa, mas não conseguiram, Henrique arremessou uma bolsa no quintal dessa residência, na qual havia um muro baixo, pegaram essa bolsa colocando a mão pelo muro. Foram buscar e viram que havia entorpecentes, cocaína e maconha, em quantidade que não se recorda, mas incompatível com o uso, além de cerca de R\$ 121,00. Os três admitiram a prática do tráfico. Não havia pessoas próximas. Os réus foram detidos na via pública. Não se lembra se havia anotações de tráfico. Não conseguiu visualizar se a bolsa foi arremessada para fora por algum morador, não soube esclarecer a pergunta do

promotor sobre essa questão. Não é verdade que o réu Matheus tenha sido detido dentro da casa. Não viu os réus vendendo drogas naquele dia. Os réus se renderam logo que os policiais apontaram as armas. Não precisou pular o muro da casa para pegar os entorpecentes. Não conhecia os réus anteriormente

A testemunha Mateus Ferreira da Silva disse que recebeu via COPOM a informação sobre uso e venda de drogas em local determinado. No mais, ratificou o relato do colega de farda. Disse que um deles tinha uma bolsa na mão, tentaram entrar em um dos barracos na comunidade, mas havia uma corrente, então eles não conseguiram. Um deles lançou a bolsa por sobre o muro dessa casa, era um muro baixo e a bolsa ficou presa em uma parte do muro, então o colega de farda conseguiu pegar. Henrique foi o réu que jogou as drogas, o depoente viu isso. Os três admitiam que trabalhavam para o tráfico, mas não explicitaram as funções. Não conhecia os réus anteriormente, apenas o adolescente, que havia sido preso três dias antes também por tráfico, no mesmo local. Não viu pessoas saindo daquela casa, mas viu o exato instante em que o parceiro retirou a sacola de drogas e cima do muro. Os réus estavam parados, conversando entre eles, mas com "olhar vivo" em direção às entradas da viela, como é de praxe.

A testemunha Eduardo disse que é irmão de Henrique. No dia anterior à prisão, o depoente retornou do trabalho na companhia do irmão, por volta de 16h30. Henrique disse que iria "dar um rolê". No dia seguinte soube que o irmão havia sido preso. Sabe que o irmão é usuário de drogas. O depoente tem empresa de divulgação e entrega de panfletos, o réu coordenava uma equipe. Não conhece o corréu Matheus. Não tem conhecimento do envolvimento do réu com tráfico ou atividades criminosas, nada falta para ele. Ouviu duas pessoas no bairro dizendo que os policiais haviam corrido atrás de Henrique, mas que ele não estava com nada. Não sabe se uma dessas pessoas era o Michel, e tampouco sabe o nome dessas pessoas. A mãe de Michel mora em frente à sua casa, na viela São José, n.º 69, salvo engano.

O réu Matheus, por seu turno, disse que foi preso em sua casa enquanto estava dormindo, mas não participou do crime. Disse que Henrique estava no quintal, batendo à porta, quando a polícia chegou. Os policiais entraram junto com Henrique e com João Gabriel. Michel também estava dormindo ali, foi acordado com a arma. Já foi condenado duas vezes por tráfico. Estudou até o primeiro ano do segundo grau. Os policiais que o abordaram naquele dia já o haviam abordado anteriormente, inclusive batido nele. Não viu drogas no momento da abordagem, mas apenas na delegacia.

Em juízo, o réu Henrique negou a acusação. Disse que estava chegando à casa de Matheus, voltando de um baile. Iria pedir para dormir na casa dele, pois estava bêbado. Nesse momento o adolescente veio correndo pela rua, com uma bolsa nas mãos. Os policiais perguntaram se ele tinha passagem, exigiram dinheiro ou que ele indicasse onde haveria uma casa bomba. Os policiais agrediram os três. No momento da prisão o adolescente assumiu o tráfico sozinho, confirmou que os réus não estavam junto com ele. Já foi condenado por tráfico, cumpriu tudo. Estudou até a oitava série. Trabalhava com seu irmão em firma de entregar panfletos. Como visto, contrariamente ao quanto alegado pela defesa, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar os acusados.

A negativa dos réus restou isolada no contexto probatório, não sendo amparada por qualquer elemento fático.

De outro lado, o depoimento dos policiais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, não se devendo desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua

parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou incontroverso que os policiais e os réus não se conheciam anteriormente aos fatos, pelo que suas declarações merecem credibilidade.

Assim, a prova produzida pela acusação autoriza a condenação dos acusados pelo crime de tráfico, na medida em que absolutamente firmes os depoimentos no sentido de que foi encontrada a droga na posse dos denunciados, após os policiais receberem denúncia anônima sobre a prática do tráfico.

Nesta medida, ainda que os acusados não tenham sido flagrados durante a efetiva entrega de entorpecentes a terceiros, na tradição, devem ser condenados nos termos da imputação inicial, a ressaltar que “para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).

Cabe, também, afastar a assertiva da Defesa quanto à existência de contradições nos depoimentos dos policiais. Ora, tratando-se de pessoas, não há que se exigir precisão absoluta nas narrativas, visto que a percepção humana é mesmo falha, sendo suficiente para a credibilidade dos relatos que se mostrem coesos em seus aspectos substanciais, exatamente como se verifica na hipótese dos autos. Portanto, as pequenas contradições apontadas não têm o condão de afastar a validade dos relatos.

Nesse sentido:

PROVA TESTEMUNHAL - Modificações e pequenas contradições verificadas em pontos secundários dos depoimentos prestados - Irrelevância: São irrelevantes eventuais modificações e pequenas contradições verificadas, em pontos secundários, nas declarações das testemunhas, se os depoimentos nas fases policial e judicial se apresentam convergentes e coerentes no essencial. (TACrimSP - Ap. nº 1.332.161/4 - São Paulo - 13ª Câmara - Rel. Lopes da Silva - J. 04.02.2003 - v.u).

Ressalta-se que o depoimento da testemunha do Juízo em nada contribuiu para a versão dos acusados na medida em que a testemunha apenas informou que seu irmão, o acusado Henrique é usuário de entorpecentes e que havia sido preso no dia anterior. Tal relato não é incompatível com os testemunhos policiais, não tendo o condão de fragilizá-los.

Quanto ao testemunho do adolescente, evidente que não se reveste da mesma credibilidade conferida aos depoimentos policiais. Isso porque é notório o interesse do adolescente em favorecer os réus, seus companheiros na empreitada criminosa, vez que já reconhecida sua participação no ato infracional equiparado ao tráfico. No caso, embora o adolescente tenha dito em Juízo que estava sozinho no local vendendo os entorpecentes, ficou demonstrado através do depoimento dos policiais, testemunhas isentas e imparciais, que ambos os réus estavam no local, sendo o acusado Henrique responsável por arremessar a bolsa contendo a drogas, enquanto todos tentavam empreender fuga.

Ainda, incabível a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no artigo 37 da Lei 11.343/06, com relação ao réu Matheus. Isso porque, o tipo penal

ali retratado se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. No caso em tela, ficou amplamente demonstrado que os acusados praticavam juntos o tráfico de entorpecentes, não se demonstrando, ao longo da instrução, que o réu Matheus assumiu apenas a função de informante ou colaborador esporádico. Ainda que atuasse como olheiro, a consistência e a estabilidade nessa função já caracterizaria a figura do artigo 33 da mencionada lei.

Oportuno destacar, ainda, que o fato de não terem os policiais avistado o réu Matheus praticando atos de mercancia, ou mesmo portando a bolsa contendo os entorpecentes, é insuficiente para afastar a sua autoria. Na hipótese, o contexto no qual inicialmente avistado o réu, após denúncia anônima relativa à prática de entorpecentes, aliado à sua imediata tentativa de fuga do local da abordagem, na companhia do réu Henrique, que portava as drogas, bem como à fantasiosa versão apresentada em interrogatório, apontam para a inequívoca participação do réu na empreitada criminal.

De igual modo, deve incidir o aumento de pena previsto pelo art. 40, VI da Lei nº 11.343/06. Isso porque a situação ali descrita tem natureza objetiva, bastando a comprovação do envolvimento de adolescente prática do delito para sua incidência, não se demandando prova eventual acerca de eventual redução de sua capacidade de entendimento e determinação, pela ação dos maiores de idade. No caso em tela, sendo inequívoco nos autos que o adolescente estava na companhia dos réus, inclusive tendo admitido a traficância, embora afastando a participação dos réus, inafastável a configuração da majorante.

Tem-se, portanto, os réus como incurso, nas sanções do artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

Réu Henrique

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico a ausência de elementos que autorizem a fixação da pena acima do mínimo legal, qual seja 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da reincidência (fls. 66/67 e 72/76), razão pela qual aumento a pena em mais 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, VI, da lei especial, visto que praticado o delito em conjunto com o adolescente João Gabriel, pelo que aumento a pena de mais 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Não há que se falar em aplicação do benefício previsto na lei especial, visto que o réu é reincidente específico. Deste modo, sua conduta está em completo descompasso com a aplicação do redutor, visto que se dirige às pessoas que não possuem envolvimento anterior na prática de tal crime, além de outros requisitos.

Ademais, não há bis in idem quando da não aplicação do redutor em razão da reincidência do réu.

Isto porque a reincidência é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

Ainda, a reincidência constitui óbice à aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, vez que um dos requisitos para que ocorra a minoração é que o acusado seja primário.

Destarte, pode a reincidência ensejar o agravamento da pena, na segunda fase de dosimetria e, ao mesmo tempo, impedir a aplicação do redutor. Vale dizer, a reincidência não é elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos elementos que obstat o aludido benefício penal, não havendo que se falar em bis in idem.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HC 393862 DF - publicado em 02.10.2017; HC 383239 DF - publicado em 27.03.2017 e; HC 410990 SP - publicado

em 13.11.2017.

Quanto ao regime inicial, este deve ser o fechado, por força de determinação legal, considerando a reincidência do réu, não havendo discricionariedade nesse particular.

Réu Matheus

O réu possui maus antecedentes, conforme se extrai da certidão de fls. 68/71, razão pela qual aplico a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Destaco que nesta fase da dosimetria utiliza-se anotação criminal distinta daquela a ser computada na segunda fase, para caracterização da reincidência, não se configurando bis in idem. Na segunda fase, verifico a existência da reincidência, considerando para tanto a condenação proferida nos autos do processo nº 0024972-35.2016.9.26.0564 (1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo), razão pela qual aumento a pena em mais 1/6, resultando em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, VI, da lei especial, visto que praticado o delito em conjunto com o adolescente João Gabriel, pelo que aumento a pena de mais 1/6, totalizando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto na lei especial, visto que o réu é reincidente específico. Deste modo, sua conduta está em completo descompasso com a aplicação do redutor, visto que se dirige às pessoas que não possuem envolvimento anterior na prática de tal crime, além de outros requisitos.

Ademais, não há bis in idem quando da não aplicação do redutor em razão da reincidência do réu.

Isto porque a reincidência é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

Ainda, a reincidência constitui óbice à aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, vez que um dos requisitos para que ocorra a minoração é que o acusado seja primário.

Destarte, pode a reincidência ensejar o agravamento da pena, na segunda fase de dosimetria e, ao mesmo tempo, impedir a aplicação do redutor. Vale dizer, a reincidência não é elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos elementos que obstam o aludido benefício penal, não havendo que se falar em bis in idem.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HC 393862 DF - publicado em 02.10.2017; HC 383239 DF - publicado em 27.03.2017 e; HC 410990 SP - publicado em 13.11.2017..

Quanto ao regime inicial, este deve ser o fechado, por força de determinação legal, considerando a reincidência do réu, não havendo discricionariedade nesse particular.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c.art. 40, VI da Lei nº 11.343/06. da Lei 11.343/06, o réu HENRIQUE RAUL PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido no regime fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal; e o réu MATHEUS SILVA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprido no regime fechado e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.

A despeito do esforço argumentativo da Defesa, descabido o pleito para revogação da prisão preventiva, pois persistem os fundamentos que ensejaram sua decretação, robustecidos agora pela sentença condenatória, conquanto recorrível. Embora não se

trate de delito praticado mediante violência ou grave ameaça, a ordem pública encontra-se ameaçada pela recalcitrância dos sentenciados, que persistem na senda delitiva, não se podendo minimizar os efeitos nefastos do delito de tráfico. Deverão, pois, os réus, permanecerem custodiados para recorrer. Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena fixada. Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor do FUNAD. Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Cumpra-se.

São Paulo, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA